

第3節 正当防衛

刑法

No.79

H20-3

(配点: 2)

月 日

月 日

正当防衛（刑法第36条第1項）の成立要件に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、正当防衛行為に対する正当防衛は成立し得ない。
- イ. 正当防衛は、急迫の侵害に対して成立するから、反撃行為を行った者が侵害を予期していた場合には正当防衛は成立し得ない。
- ウ. やむを得ずにした行為として正当防衛が成立するには、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要するから、防衛行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えた場合には正当防衛は成立し得ない。
- エ. 正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、加害者の過失行為に対しては正当防衛は成立し得ない。
- オ. 急迫不正の侵害がないのにあると誤信して、防衛の意思で反撃行為を行った場合には正当防衛は成立し得ない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.79

正当防衛の成立要件

正答率

H20-3

正解

2

94%

ア 正しい

正当防衛は、「不正」な侵害に対してのみ可能である（36条1項）。「不正」の意義につき、違法であることを意味するとされている（大判昭8.9.27）。正当防衛行為は、違法性が阻却されるため、「不正」な侵害ではない。それゆえ、正当防衛に対する正当防衛は成立し得ず、この場合は、緊急避難が成立し得るにすぎない。

イ 誤っている

侵害が予期されたものであった場合、侵害の急迫性を肯定することができるにつき、判例は、「当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないと解するのが相当である」としている（最決昭52.7.21、百選Ⅰ〔第7版〕23事件）。理由として、「刑法36条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではない」ということを挙げている。よって、正当防衛の他の要件を満たせば、正当防衛が成立する。

ウ 誤っている

「やむを得ずにした行為」につき、判例は、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味するのであって、反撃行為が右の限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではないと解すべきである」としている（最判昭44.12.4）。正当防衛は、「不正対正」の関係にある関係上、厳格な法益の均衡は要求されないからである。よって、正当防衛の他の要件を満たせば、正当防衛が成立する。

エ 誤っている

「不正」とは、違法であることを意味する（大判昭8.9.27）。過失は、構成要件要素である。構成要件に該当すれば、違法性が推定される。よって、過失行為は違法性が推定されるので、違法性阻却事由がなければ、侵害者の過失行為も、不正な侵害にあたり得ることになるため、他の要件を満たせば正当防衛が成立する。

オ 正しい

急迫不正の侵害が存在しないのに、それが存在すると誤信して、それに対し反撃行為を行った場合が誤想防衛の典型であり、誤信した侵害が実際に存在するとした場合に許容される範囲の行為を行ったときには、故意は阻却され、誤信したことについて過失があれば、過失犯が成立することになる。いずれにしても、存在しない急迫不正の侵害が存在することとなるわけではないから、正当防衛は成立し得ない。